

1500826-09.2021.8.26.0618
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Gustavo de Campos Machado
Comarca: Caçapava
Foro: Foro de Caçapava
Vara: Vara Criminal
Data de Disponibilização: 17/03/2022

... senda, confira-se:
"APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS -
CONDENAÇÕES - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA ESTABILIDADE -
ABSOLVIÇÕES MANTIDAS - DOSIMETRIA - REPAROS - RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE.
'Cabalmente demonstradas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de
drogas, as condenações dos réus são ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Caçapava
Foro de Caçapava
Vara Criminal
Rua Marquês do Herval, 269, Caçapava-SP - cep 12281-510
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500826-09.2021.8.26.0618 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500826-09.2021.8.26.0618
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de
Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante
- 2154167/2021 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 18366843 - Delegacia de Polícia
de Caçapava, 1239/21/323 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 2154167 - Delegacia de
Polícia de Caçapava, 2154/2021 - Delegacia de Polícia de Caçapava
Autor:
Justiça Pública
Réu:
RYAN DOS SANTOS ROSA e outro
Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gustavo de Campos Machado

VISTOS.

RYAN DOS SANTOS ROSA e DANILO HENRIQUE ALVES DOS SANTOS, qualificado nos autos,
foram denunciados como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 c/c o
artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, porque, no dia 08 de junho de
2021, por volta das 08 horas e 10 minutos, na Rua Vereador Rui Barbosa, Pinus do
Iriguassu II, nesta cidade e Comarca de Caçapava, RYAN, menor de vinte e um anos, e
DANILO, previamente ajustados e com unidade de desígnios, supostamente, guardavam e

mantinham em depósito, para fins de comércio e entrega a consumo de terceiros, drogas, consistentes em 53 (cinquenta e três) porções de cocaína e 47 (quarenta e sete) porções de Cannabis sativa L. (maconha), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Os réus foram notificados (fls.130/131), apresentaram defesa prévia (fls.140/143), sendo recebida a denúncia em 20/09/2021 (fls.169/171) e os acusados devidamente citados.

Durante a instrução, realizada virtualmente em razão da pandemia do novo coronavírus, foram ouvidas duas testemunhas comuns, bem como foram os réus interrogados. Em debates orais, o parquet pugnou pela condenação dos réus pelo crime de tráfico e associação ao tráfico, enquanto a defesa requereu sua absolvição.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A presente ação penal merece ser julgada procedente.

A materialidade delitiva encontra-se provada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01), Boletim de Ocorrência (fls. 02/04), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 10/11), Laudo de Constatação Provisória (fls. 15/17), Exame Químico-Toxicológico (fls.147/149) e pela prova oral coligida em juízo.

A autoria dos réus desponta nítida e incontestável.

Em interrogatório judicial, RYAN DOS SANTOS ROSA disse que tem 20 anos, é solteiro, não tem filhos, antes de ser preso fazia bicos de servente de pedreiro, já foi processado por tráfico de drogas, mas não foi condenado criminalmente ainda. Quanto aos fatos, negou sua autoria. Declarou que foi ao local comprar uma bucha de maconha, tanto que estava com apenas R\$4,00 no bolso no momento da abordagem. No entanto, quando chegou ao local para comprar maconha, viu a viatura policial e um monte de pessoas correndo, razão pela qual voltou para trás. Disse que não estava com Danilo no dia, mas admitiu que o encontrou próximo ao pé de manga antes de serem abordados. Contou que ele e Danilo não estavam com qualquer sacola com drogas na mão. Declarou que não dispensou nada na lixeira e que não é verdade a afirmação dos policiais militares de que dispensou R\$534,00 na lixeira. Não sabe o motivo pelo qual os policiais disseram que o interrogando dispensou algo na lixeira, acreditando que a ele foi atribuída tal conduta por ser a pessoa mais próxima da lixeira. Reafirmou que iria comprar maconha na biqueira e que não tem relação com o tráfico. Não conhecia Danilo anteriormente, tampouco os policiais que o prenderam. Ao ser interrogado em juízo, o acusado DANILLO HENRIQUE ALVES DOS SANTOS declarou que tem 22 anos, é solteiro, não tem filhos, faz bicos, nunca foi processado criminalmente. Quanto aos fatos, disse que eles são parcialmente verdadeiros, pois estava traficando sozinho. Admitiu que Ryan estava com o interrogando no momento da abordagem e que ele ficava com o dinheiro da venda de drogas pelo interrogando. Conhecia Ryan há uns três dias; conheceu Ryan no local, isto é, no Pinus (biqueira), mas não sabe se ele é envolvido no tráfico. Reafirmou que estava morando com Ryan há três dias, mas, no dia dos fatos, ele apenas foi encontrar com o interrogando para pegar uma bucha para fumar, momento em que lhe entregou o dinheiro produto da venda para guardar em casa caso fossem abordados. Explicou que para não perder o lucro, deixou o dinheiro com Ryan, mas este não tinha nada a ver com as drogas. Pegou a droga com o gerente do Pinus. Mudou-se do Pinus depois que saiu da prisão e atualmente voltou a morar com sua mãe. Foi por causa de seu vício em drogas que passou a traficar. Ryan não concorreu no tráfico, reafirmando que o corréu chegou no local para comprar drogas e resolveu dar-lhe o dinheiro para não perder o lucro das vendas que seria destinado a pagar uma dívida de R\$780,00 em drogas.

Todavia, o agente militar REGINALDO LEONARDO DOS SANTOS, em juízo, disse que, no dia, estavam em patrulhamento pelo Pinus II quando avistaram dois indivíduos, identificados pelos réus Ryan e Danilo, embaixo de um pé de manga, local já conhecido como ponto de drogas. Na sequência, ao notarem a presença da equipe, um deles largou uma sacola e ambos saíram andando. Viram que Ryan tirou algo do bolso e colocou numa lixeira. Verificada a lixeira, encontraram R\$534,00 e, no local onde foi dispensada a sacola, localizaram 45 buchas de maconha e 53 porções de cocaína.

Em conversa informal, Danilo assumiu que largou a sacola com drogas. No momento da abordagem só havia os dois réus no local. Posteriormente, Danilo falou que largou a sacola, mas ambos informalmente admitiram que estavam na venda de drogas. O declarante conhecia Danilo, mas não do tráfico.

A corroborar, o policial militar ARISTIDES DA LEME DA CUNHA JUNIOR, em regular contraditório, confirmou que, na data dos fatos, estavam patrulhando no Pinus, em local conhecido pelo tráfico, quando avistaram os réus debaixo do pé de mangueira, momento em que um deles jogou uma sacola no chão ao notar a presença da polícia. Ao efetuar a abordagem dos réus, Ryan enfiou um objeto em uma lixeira, em cujo interior localizaram R\$530,00 em espécie. Deslocaram-se até o pé de mangueira, onde localizaram na sacola dispensada 43 buchas de maconha e 53 porções de cocaína. Danilo confirmou que largou a sacola com drogas. Não se recorda, porém, se Ryan confirmou que o dinheiro era dele, mas ele foi visto dispensando o numerário na lixeira. Danilo admitiu informalmente a prática do tráfico, não se lembrando se Ryan também admitiu a prática do tráfico. Conhecia a família de Danilo, especificamente seu pai, e atesta que o réu é um rapaz inteligente.

Pois bem!

Embora DANILO tente eximir RYAN de culpa, é forçoso reconhecer que as versões dos réus são absolutamente inverossímeis e contraditórias.

Por primeiro, DANILO disse em seu interrogatório judicial que conhecia RYAN há pelo menos três dias e que ambos estavam dividindo moradia desde que se mudou para o bairro do Pinus.

Diversamente, RYAN asseverou em juízo que não conhecia o acusado DANILO anteriormente e que foi ao local apenas para comprar uma bucha de maconha na biqueira.

Ademais, DANILO assumiu a posse e propriedade das drogas encontradas na sacola por ele dispensada.

RYAN, em sentido oposto, disse que nem ele nem DANILO estavam na posse de qualquer sacola.

Adicionalmente, DANILO asseverou em juízo que repassou o dinheiro do tráfico a RYAN para não perder o produto da venda de drogas, já que esse dinheiro seria destinado a quitar suas dívidas com drogas.

Por outro lado, RYAN afirmou que nada lhe foi repassado por DANILO e que não dispensou nenhuma quantia em dinheiro antes de ser preso, seja na lixeira, seja em qualquer lugar.

Por fim, a versão de RYAN, além de colidir com a narrativa de DANILO, contrasta veementemente com o testemunho dos policiais militares ARISTIDES e REGINALDO, os quais foram firmes e uníssonos em dizer que surpreenderam RYAN dispensando um objeto na lixeira, identificado posteriormente como dinheiro, no valor total de R\$ 534,75 em notas trocadas.

Além do mais, o policial militar REGINALDO também relatou que ambos os réus confessaram informalmente a prática do crime de tráfico de entorpecentes por ocasião de sua abordagem.

Tais elementos, evidentemente, comprovam que RYAN e DANILO estavam envolvidos com tráfico e que as drogas a ambos pertenciam e se destinavam ao comércio nefasto. Cumpre salientar que a condição de policial - seja militar ou civil - não invalida por si só seus testemunhos, pois não estão impedidos de depor e se sujeitam ao compromisso de dizer a verdade, como toda e qualquer testemunha.

Afora isso, não foi produzida pela d. Defesa qualquer prova de suspeição ou impedimento dos agentes públicos, apesar de ter a oportunidade para tanto, nos termos do artigo 156, caput, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, "o valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se

harmonizam com os outros elementos probatórios idôneos" (STF - HC nº 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96, p. 39.846).

Enfim, o dolo de traficar de DANILO e RYAN decorre das circunstâncias e local da prisão, conhecido ponto de drogas dessa Comarca, bem como do encontro de variadas e considerável quantidade de entorpecentes e dinheiro, além de sua confissão informal aos policiais militares.

Para Fernando de Almeida Pedroso, "em sede de tráfico de substância entorpecente, constituem prova indiciária do malsinado e vil comércio, exemplificativamente, a quantidade apreendida de estupefacientes, denotando sua incompatibilidade com a destinação para o próprio uso; a forma de fragmentação e acondicionamento do tóxico, confeccionado em diversas embalagens ou unidades distintas e individuais, indicando o propósito de venda a varejo" (cf. Prova Penal, 2ª ed., RT, 2004, item 5, pág. 96).

Considere-se, ainda, que "[...] não é indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido [...]" (RT 729/542).

Todavia, ao contrário do que argumentou o Ministério Público em debates, apesar de certa a traficância pelos acusados DANILO e RYAN, não há elementos nos autos que demonstrem, com segurança, a presença de associação estável e permanente para o tráfico, isto é, o ânimo entre os acusados para formar e organizar suas ações, previamente, destinadas à prática do comércio espúrio.

Lembre-se que para caracterização do crime de associação para o tráfico é necessário que se comprove o caráter estável e duradouro da associação, não bastando para tanto a existência de mero concurso de agentes, tal como no caso em apreço.

Nessa senda, confira-se:

"APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - CONDENAÇÕES - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA ESTABILIDADE - ABSOLVIÇÕES MANTIDAS - DOSIMETRIA - REPAROS - RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE.

'Cabalmente demonstradas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, as condenações dos réus são impositivas. Entretanto, somente se configura o delito autônomo de associação (art. 35 da Lei n.º 11.343/06) se houver efetiva comprovação da existência de vínculo associativo, com características de estabilidade e permanência, não sendo suficiente para a configuração do tipo em questão o concurso eventual de agentes. Logo, não comprovada a estabilidade da associação, a manutenção das absolvições por este crime é imperativa (...)" (TJ/MG - A.C. n.º 1.0701.07.197329-4/001 - Rel. Des. Eduardo Brum - j. 18/11/2008 - D.O.P.J. 25/11/2008, g.n.).

Desse modo, comprovadas a autoria e materialidade apenas do crime de tráfico de drogas, devem os acusados ser condenados nos estritos termos da denúncia.

Passo à dosimetria da pena, com a sua devida individualização, conforme o sistema trifásico determinado pelo artigo 42 da Lei n.º 11.343/06 c.c. artigo 59 do Código Penal.

Na primeira fase, além das circunstâncias judiciais serem favoráveis aos réus, não se pode negar que, conquanto uma das drogas seja de natureza extremamente nociva (crack), a quantidade apreendida não é tão expressiva assim (53 porções de cocaína e 47 porções de Cannabis sativa L.), razão pela qual fixo a pena base no mínimo legal, a saber, 05 anos de reclusão, além 500 dias-multa.

A propósito: "O art. 42 da Lei nº 11.343/06 impõe ao Juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, tanto na fixação da pena-base, quanto na determinação do grau de redução da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da nova Lei de Tóxicos" (STJ, 5ª T., HC 225.575/ES, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Dje. de 05-06-12, grifei).

Ainda, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n.º 11.343/06, na fixação da pena do crime de tráfico de drogas, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente. Nesse sentido: STJ, HC

n.º 402.845/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/09/2017, DJe 21/09/2017.

No tocante à segunda fase de dosimetria, não há atenuantes, já que a confissão de DANILO foi parcial e com o objetivo de induzir esse juízo a erro, tampouco agravantes.

Na derradeira etapa, ausentes causas de aumento de pena. Todavia, os réus fazem jus à diminuição de 2/3 das penas com fulcro no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, o que perfaz o total de 01 ano e 08 meses de reclusão, além de 166 dias-multa, pois, além de primários e sem antecedentes criminais (fls. 225/228), não há provas de que integrem organização criminosa.

Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, uma vez que não há nos autos elementos que comprovem a capacidade econômica da ré.

Excepcionalmente, fixo o regime aberto para o início do cumprimento da pena, tendo em vista as circunstâncias judiciais favoráveis aos acusados, sua primariedade (fls. 225/228) e o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Não obstante este magistrado tenha reiteradamente decidido em casos idênticos de maneira diversa, ao adotar regime fechado no tráfico privilegiado, curvo-me ao recente posicionamento adotado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Habeas Corpus n.º 596.603 - SP (2020/0170612-1), de relatoria do MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ, adotando regime mais brando (aberto), em observância aos princípios da hierarquia jurisdicional e da segurança jurídica.

Em atenção ao balizado pela C. Superior Instância, reputo preenchidos os requisitos previstos pelo artigo 44, do Código Penal, razão pela qual substituo a pena privativa por duas penas restritivas de direito, quais sejam, a prestação de serviços à comunidade, que serão especificados pelo juízo da execução, e a prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo em favor de entidades assistenciais, recaiando, preferencialmente, em favor daquelas voltadas a reabilitação de dependentes químicos.

Ainda, quanto à possibilidade de substituição da pena corporal por restritiva de direitos, cabe observar o entendimento atual do Supremo Tribunal Federal: "A Turma concedeu parcialmente a ordem de habeas corpus para possibilitar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ao paciente condenado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, desde que cumpridos os demais requisitos exigidos pela lei. Salientou-se que, uma vez verificada essa possibilidade, não há impedimento para que se fixe o regime inicialmente aberto para o cumprimento da pena, já que o objetivo da conversão é evitar o encarceramento. Frisou-se, ainda, que esse posicionamento busca apenas adequar a fixação do regime ao entendimento do STF, aplicando-se especificamente aos delitos de tráfico e apenas em razão da declaração de inconstitucionalidade das expressões da lei que vedavam a substituição. Precedentes citados do STF: HC 97.256-RS, DJe 15/12/2010; HC 104.423-AL, DJe 7/10/2010; HC 102.678-MG, DJe 23/4/2010, e HC 105.779-SP, DJe 21/2/2011". HC 196.199-RS, Rel. Min. Gilson Dipp, julgado em 5/4/2011.

DISPOSITIVO

Posto isto e do mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e, em consequência, CONDENO os acusados RYAN DOS SANTOS ROSA e DANILO HENRIQUE ALVES DOS SANTOS como incurso no artigo 33, caput, c.c §4º da Lei n.º 11.343/06, impondo-lhes às penas de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pelas razões excepcionais acima mencionadas, além de 166 dias-multa, no menor valor unitário, pela prática do tráfico privilegiado.

Substituo a pena privativa imposta por duas restritivas de direito, quais sejam, a prestação de serviços à comunidade, que serão especificados pelo juízo da execução, e a prestação pecuniária, no valor de um salário-mínimo em favor de entidades assistenciais, recaiando, preferencialmente, em favor daquelas voltadas a reabilitação de dependentes químicos.

Tendo em vista o regime de pena aplicado e o longo período em que o acusado RYAN encontra-se preso por esse processo, revogo sua preventiva, facultando-lhe o direito de recorrer em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado, COM URGÊNCIA.

Faculto a ambos os réus o direito de recorrer em liberdade.

Autorizo a incineração das substâncias entorpecentes apreendidas, guardando-se pequena quantidade para eventual exame futuro, com a ressalva de que, com o advento da Lei nº 11.343/06, deverá ser observado o artigo 32, §2º, que exige a presença do Ministério Público, bem como de autoridade sanitária competente no local da incineração, elaborando-se, ainda, auto circunstanciado e perícia.

Outrossim, observo que os réus não fizeram prova da procedência lícita da importância em dinheiro apreendida em seu poder. Assim, conclui-se que são produtos do tráfico de entorpecentes por eles praticado e, por este motivo, com fundamento no artigo 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal e artigo 62 da Lei n.º 11.343/06, declaro, após o trânsito em julgado, o perdimento, em favor da União, da importância em dinheiro apreendida nos autos.

Os acusados deverão arcar com o pagamento, ao final da ação, da taxa judiciária, no valor de 100 UFESPs, conforme o artigo 4º, §9º, alínea a da Lei Estadual nº 11.608/03.

Com o trânsito em julgado: (i) expeça(m)-se guia(s) de execução; (ii) nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao IIRGD; (iii) oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; (iv) notifique(m)-se o(s) réu(s) para pagamento da pena de multa; (v) se o caso, expeça-se certidão de honorários em favor da advogada nomeada nos autos.

Publique-se, intime-se e cumpra-se.

Caçapava, 17 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA